

1502415-23.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2245955/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

1ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos-SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502415-23.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502415-23.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2245955/2019 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 7014869 -

DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 1697/19/938 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 2245955 -

DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 1697/19/938 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 2245955 -

DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 1697/19/938 - DEL.POL.PLANTÃO VALINHOS, 2245955 - 01º

D.P. VALINHOS, 1697/19/938 - 01º D.P. VALINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BRUNO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de GABRIEL BRUNO DE OLIVEIRA, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Narra-se na denúncia, em resumo, que no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 17h40, na Rua Vitória Baron, n. 17, bairro Figueira, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Valinhos, o acusado manteve em depósito, para venda ou entrega a terceiros, 25 porções de cocaína, totalizando 20g, e 4 porções de Cannabis Salita

L., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que “Policiais Militares, na posse de mandado de prisão contra o denunciado, extraído do processo judicial n. 0007543-25.2015.8.26.0650, dirigiram-se até o local informado e avistaram-no defronte à residência e este, ao perceber a aproximação da polícia, adentrou no imóvel, tentando se esquivar da ação policial, mas foi interceptado e contido. Abordado e entrevistado informalmente, disse aos policiais que havia droga no interior do imóvel, indicando o local em que as armazenava (gaveta no armário da cozinha). Ato contínuo, os policiais encontraram e apreenderam 25 pedras de crack e 4 porções de maconha, todas embaladas de forma individualizada, além de diversos apetrechos comumente usados para preparação e embalo de tóxico, a saber: duas balanças de precisão, tesoura, alicate, fita adesiva e diversos pequenos sacos plásticos” (fls. 02/03).

Promovida a notificação (fls. 133), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 138/139).

A denúncia foi recebida em 15/02/2022 (fls. 145/147)

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório. Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa técnica apresentou memoriais (fls. 206/212). Alegou, em síntese, que (a) as provas produzidas são nulas, pois o denunciado foi absolvido do processo criminal cujo mandado de prisão ensejou a apreensão da droga ora debatida, (b) há nulidade das provas, ainda, em razão de a testemunha Edilene ter informado que não autorizou a entrada dos policiais na residência, (c) não restou demonstrado que a droga foi localizada na residência do réu. Pugnou pela absolvição do réu.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Embora haja impugnações específicas quanto à validade das provas produzidas, entendo haver confusão com o mérito e, portanto, com ele serão analisadas. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

Para o exame da comprovação da materialidade e da autoria do fato descrito na denúncia, são relevantes, em especial, os seguintes elementos de informação e de prova: auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 40/42), pelo laudo de exame pericial provisório (fls. 46/48) e definitivo (fls. 80/82), auto de exibição/apreensão (fls. 43/44), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

No ponto, passa-se a sumarizar os depoimentos colhidos.

A testemunha Leozino Jesse Bernardes dos Santos (policial militar), ouvido em solo policial (fls. 09), relatou que (a) se encontrava na companhia do Cabo Daniel e estavam na posse de mandado de prisão a ser cumprido contra o acusado, (b) chegando no endereço de Gabriel, avistaram um indivíduo parado na calçada, que adentrou rapidamente a residência ao avistar a viatura da polícia, (c) estacionaram a

viatura e visualizaram o acusado no quintal, estando o portão da residência aberto, (d) chamaram por Gabriel, mas este ignorou os comandos, momento em que o depoente e seu companheiro de farda realizaram a prisão no quintal, (e) o réu é conhecido nos meios policiais como traficante de drogas, (f) foi-lhe indagado acerca da existência de entorpecentes no interior da residência, momento em que Gabriel assumiu que mantinha droga naquele local, (g) houve solicitação à genitora do réu para ingresso no imóvel, que lhes franqueou a entrada, (h) Gabriel disse aos policiais onde se encontrava a droga e os demais objetos apreendidos. Em juízo, a testemunha aduziu que (i) tinham um mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor de Gabriel, (j) foram até o endereço constante do mandado, visualizando o denunciado do lado de fora do imóvel e, ao avistar a viatura policial, tentou ingressar na casa, (k) na revista pessoal não foi encontrado nada de ilícito, mas Gabriel lhes confessou que havia droga armazenada dentro da casa, (l) a entrada dos milicianos foi franqueada pela genitora do réu, (m) a droga foi encontrada em uma gaveta no armário da cozinha, local em que o próprio Gabriel informou aos policiais.

A testemunha Daniel Ferreira (policial militar), ouvido em solo policial (fls. 07), apresentou em síntese o mesmo relato de seu companheiro Leozino, supratranscrito. No mesmo sentido, ao ser ouvido em juízo, endossou a versão apresentada por Leozino.

A testemunha não compromissada, Edilene Aparecida Astolfi de Oliveira, genitora do acusado, em solo policial (fls. 10), alegou que (a) encontrava-se no quintal de sua casa brincando com seu neto, estando Gabriel e David no interior da casa, (b) avistou dois policiais adentrando a residência, sem sua permissão, e ao indaga-los sobre o ocorrido, foi impedida de adentrar em sua própria casa, (c) minutos depois, saíram do imóvel com Gabriel e David, alegando que o primeiro estava com mandado de prisão em aberto, (d) disseram-lhe os policiais, ainda, que foi encontrada droga no interior da residência, tendo Gabriel confessado que era de sua propriedade, (e) tem conhecimento que o réu, seu filho, é usuário de drogas, mas não traficante. Em juízo, a testemunha não compromissada disse que (f) o portão da residência estava aberto, pois sempre sem mantém desta forma, (g) quando os policiais chegaram, se encontrava no quintal da casa, que fica na parte da frente, com sua filha, (h) os milicianos lhe perguntaram onde Gabriel se encontrava, tendo a declarante indicado que seu filho estava na cozinha, tendo os policiais se dirigido diretamente para lá.

A testemunha David Clayton Barbosa, primo do acusado, em solo policial (fls. 11) alegou que (a) estava na casa de seu primo Gabriel, onde também estava sua tia Edilene, (b) o portão da residência estava aberto, e em dado momento apareceram dois policiais dentro da casa pedindo por drogas, pois sabe que seu primo já foi preso anteriormente pelo mesmo motivo, (c) Gabriel acabou dizendo aos policiais onde a droga se encontrava, bem como os apetrechos apreendidos, (d) somente após a abordagem apresentaram o mandado de prisão, (e) em nenhum momento houve pedido de permissão para ingresso na residência. Ouvido em Juízo, a testemunha disse que (f) quando da entrada dos policiais, se encontrava na sala da casa, (g) os milicianos permaneceram na residência por cerca de 10 a 15 minutos, (h) não sabe informar se algo de ilícito foi encontrado, pois foi "colocado de canto" pelos policiais quando da busca pelo imóvel.

A testemunha não compromissada Gabriela Bruna de Oliveira, irmã do acusado, ouvida em Juízo, alegou que (a) no dia dos fatos se encontrava no quintal de casa com sua mãe, (b) os policiais entraram porque o portão estava aberto, (c) Edilene, sua genitora, bem como do acusado, informou aos policiais que Gabriel se encontrava na cozinha de casa, (d) não presenciou a abordagem dentro do imóvel, pois permaneceu do lado de fora.

Por fim, o acusado Gabriel Bruno de Oliveira, quando da prisão em flagrante,

manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 12). Em Juízo, em fase de interrogatório, alegou que (a) os fatos constantes da denúncia não são verdadeiros, (b) quando os policiais apareceram, já se encontrava dentro de casa, (c) os policiais “chegaram entrando”, apresentando o mandado de prisão apenas depois da abordagem, (d) não houve pedido de autorização para ingresso na residência, (e) vasculharam a cozinha, local em que se encontrava sozinho, (f) a balança de precisão e os outros itens, com exceção da droga, não sabe a origem, tendo aparecido somente na delegacia.

Extraí-se da dinâmica apresentada que os militares Leozino e Daniel, em posse de mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor de Gabriel, se dirigiram até o endereço do acusado. Ao se aproximarem, identificaram o acusado do lado de fora de casa – tendo em vista ser conhecido nos meios policiais. Ao visualizar a aproximação dos policiais, Gabriel buscou ingresso em sua residência, sendo logo perseguido e detido pelos policiais. Até este ponto, nada há de ilícito que possa macular os elementos de prova colhidos. Ocorre que as condutas posteriores dos agentes estatais acabaram aviltando a prova da materialidade delitiva. Explico.

Diante do acervo probatório acima sumarizado, a despeito das substanciosas razões apresentadas pelo Ministério Público em alegações finais pela condenação, constata-se que a absolvição por ausência de prova (CPP, art. 386, VII) se impõe, pois é consectário da ilicitude advinda do desvio de finalidade da incursão policial quando da entrada em domicílio (meio de obtenção de prova), a qual implica a ilicitude da subsequente apreensão das drogas e respectiva perícia, por ser prova derivada, à luz do art. 5º, LVI, da CR/1988 e do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

Registre-se, no ponto, que não há outras provas obtidas por fonte independente que possam, com base em nexo de causalidade diverso, dar amparo à comprovação do fato-crime, à luz do art. 157, § 1º, do CPP, e tampouco há no caso demonstração de hipótese de descoberta inevitável pelos trâmites típicos e de praxe da investigação, à luz do art. 157, § 2º, do CPP. O laudo pericial sobre as drogas apreendidas é o único meio de prova admitido na legislação processual penal para a comprovação do tráfico de drogas (CPP, art. 158), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg no HC 492.906/MS, Quinta Turma, DJe 12/09/2019 e HC 497.242/CE, Sexta Turma, DJe 12/08/2019).

Com efeito, a leitura da denúncia, conjugada aos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório, revela que, na data dos fatos, munidos de mandado de prisão em desfavor de Gabriel, se dirigiram até sua residência para cumprimento. Então, visualizaram o réu entrando em sua casa, partindo em seu encalço residência adentro, procedendo à sua prisão emanada de ordem judicial.

Registre-se: o mandado emanado pelo Estado-Juiz consistia em prisão de Gabriel, e não busca e apreensão em seu domicílio. Trata-se de ordens judiciais com finalidades distintas. Mesmo em se admitindo a legalidade do ingresso dos agentes policiais na residência do acusado para o cumprimento do mandado de prisão, não há justificativa para procederem a buscas no local na tentativa de encontrar materiais ilícitos. A doutrina denomina tal conduta de “fishing expedition”. Trata-se, inclusive, de entendimento encampado pelo C. STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

4. Sobre a gravação audiovisual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas"), reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".

5. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência, conforme se extrai da exegese do art. 248 do CPP, segundo o qual, "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência".

6. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo – vinculado à justa causa – para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.

7. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

8. Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo

definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fígados, muito menos a quantidade" (ROSA, Alexandre Moraes da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390).

9. Sobre o desvio de finalidade no Direito Administrativo, Celso Antonio Bandeira de Mello ensina: "Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os atos incursos neste vício – denominado 'desvio de poder' ou 'desvio de finalidade' – são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à própria lei" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 27 ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 106).

10. No caso dos autos, o ingresso em domicílio foi amparado na possível prática de crime de falsa identidade, na existência de mandado de prisão e na suposta autorização da esposa do acusado para a realização das buscas.

10.1 O primeiro fundamento – crime de falsa identidade – não justificava a entrada na casa do réu, porque, no momento em que ingressaram no lar, os militares ainda não sabiam que o acusado havia fornecido anteriormente à guarnição os dados pessoais do seu irmão, o que somente depois veio a ser constatado. Não existia, portanto, situação fática, conhecida pelos policiais, a legitimar o ingresso domiciliar para efetuar-se a prisão do paciente por flagrante do crime de falsa identidade, porquanto nem sequer tinham os agentes públicos conhecimento da ocorrência de tal delito na ocasião.

10.2 No tocante ao segundo fundamento, releva notar que, além de não haver sido seguido o procedimento legal previsto no art. 293 do CPP, não se sabia – com segurança – se o réu estava na casa, visto que não fugiu da guarnição para dentro do imóvel com acompanhamento imediato em seu encalço; na verdade, o acusado tomou rumo ignorado, com notícia de que provavelmente estaria escondido dentro do cemitério, mas os agentes foram até a residência dele “colher mais informações”.

10.3 Mesmo se admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para captura do acusado – em cumprimento ao mandado de prisão ou até por eventual flagrante do crime de falsa identidade –, a partir das premissas teóricas acima fundadas, nota-se, com clareza, a ocorrência de desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato. Isso porque os objetos ilícitos (drogas e uma munição calibre .32) foram apreendidos no chão de um dos quartos, dentro de uma caixa de papelão, a evidenciar que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo réu – certamente portador de dimensões físicas muito superiores às do referido recipiente –, mas sim verdadeira pescaria probatória dentro do lar, totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o paciente.

10.4 Por fim, quanto ao último fundamento, as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a esposa do paciente – adolescente de apenas 16 anos de idade – teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso no domicílio do casal, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor de seu cônjuge. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.

10.5 A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no

caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela derivados, porque decorrentes diretamente dessa diligência policial. É preciso ressaltar, contudo, que a condenação pelo crime do art. 307 do CP (falsa identidade) não é atingida pela declaração de ilicitude das provas colhidas a partir da invasão de domicílio, eis que a prática do delito, ao que consta, foi anterior ao ingresso dos agentes no lar do acusado.

11. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio do acusado, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo das imputações relativas aos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003."

(STJ. SEXTA TURMA. Habeas Corpus n. 663055/MT, rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. em 22 de março de 2022, destacado).

Diante da dinâmica fática supra sintetizada, bem evidenciada pela instrução processual, não há como afastar a ilicitude do meio de obtenção de prova empregado, pois flagrante o desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão, que acabou se tornando em verdadeira busca e apreensão no domicílio, sem mandado específico para tanto. Tendo em vista que toda a prova da materialidade do delito foi obtida a partir do desvio de finalidade das ordens emanadas pelo Poder Judiciário, deve ser reconhecida a sua ilicitude por derivação.

O fato de Gabriel ter, à época, mandado de prisão expedido – em processo criminal envolvendo tráfico de drogas – não justifica a devassa em sua residência sob discricionariedade dos agentes de segurança pública. Aliás, conforme restou incontroverso nos autos, o acusado residia na casa de sua genitora, estando presentes no momento sua irmã, seu primo e um sobrinho de tenra idade.

A entrada forçada em domicílio tem natureza excepcional e, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 (CR/88), só se justifica em casos de (a) prestação de socorro, (b) desastre, (c) flagrante delito e (d) determinação judicial (neste último caso, durante o dia - CPP, art. 241).

A partir de uma interpretação teleológica do referido dispositivo constitucional, é possível constatar que a quebra da inviolabilidade domiciliar só se dá, em regra, mediante determinação judicial prévia e durante o dia: trata-se de medida restritiva de direito fundamental submetida a reserva jurisdicional. Excepcionalmente, nas três situações de urgência elencadas no referido dispositivo normativo (prestação de socorro, desastre e flagrante delito), é possível a entrada forçada em domicílio independentemente de autorização judicial prévia, e em qualquer hora do dia.

Nessa linha de raciocínio, a expedição de mandado judicial de busca domiciliar consiste em medida prévia à efetivação de prisão ou de apreensão de coisas e elementos de convicção no curso da persecução penal. Tal diligência depende, em suma, de fundadas razões da presença das pessoas/coisas a serem presas/apreendidas no interior da residência em que se visa a executar a medida. Tal é a inteligência do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP).

Assim, diante da aparência da natureza criminosa de determinado fato (*fumus commissi delicti*) e de indícios da existência de pessoas envolvidas ou de quaisquer elementos de convicção quanto a tal fato em determinada residência, autoriza-se a expedição de mandado de busca domiciliar no curso da persecução penal. Sem tais fundadas razões supra, obsta-se a expedição de mandado de busca exploratória, como instrumento de varredura geral, como consectário da proteção constitucional à privacidade e à inviolabilidade do domicílio (CR/88, art. 5º, X e XI).

No julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a orientação de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em

fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Assim, caso o agente policial verifique fundadas razões da ocorrência de flagrante delito em determinada residência, autoriza-se a imediata entrada forçada em domicílio, a qualquer tempo, independentemente da prévia expedição de mandado judicial de busca, pois em tal situação há presunção de urgência para a repressão imediata da conduta criminosa atualmente em curso, o que justifica a postergação do controle jurisdicional da validade do ato, na linha das situações urgentes já previstas no art. 5º, XI, da CR/88. Sobre o afastamento de tal presunção de urgência nos casos de crimes de perigo abstrato permanentes e sem risco de perda/destruição da prova, cf. STJ, HC 598.051/SP, Sexta Turma, DJe 15.3.2021; HC 616.584/RS, Quinta Turma, DJe 6.4.2021.

Nessa ordem de ideias, vale notar que, desde o julgamento do RE 603.616/RO pelo Plenário do STF, evidenciou-se na jurisprudência que o standard probatório exigido para a expedição de mandado judicial de busca domiciliar (CPP, art. 240) e o standard probatório exigido para a entrada policial forçada em domicílio diante de flagrante de crime permanente (CR/88, art. 5º, XI) é exatamente o mesmo: fundadas razões da ocorrência da infração penal e da existência de elementos de convicção quanto a ele no interior da residência.

Assim, tanto a validade da entrada policial forçada em domicílio diante de flagrante de crime permanente quanto a validade do mandado judicial de busca domiciliar são analisadas à luz do mesmo critério: com base em seus fundamentos (fatos de conhecimento anterior à medida), e não com base em seus resultados (fatos de conhecimento posterior à medida). Logo, se o policial promove a entrada policial forçada em domicílio a partir de fundadas razões quanto à situação de flagrância de crime permanente, a medida não será invalidada apenas em razão de ter tido resultado negativo (não obtenção de prova do crime). O mesmo raciocínio se aplica ao mandado judicial: a decisão que determina sua expedição será válida se estiver devidamente fundamentada em fundadas razões do ilícito, e não se o resultado do cumprimento do mandado for positivo.

Nesse rumo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) já firmou a orientação de que não pode a polícia avançar "imóvel adentro, em abusivo proceder, amparado em mera desconfiança" e fez constar a advertência de que a validade da busca domiciliar depende de seus fundamentos e não de seus resultados: "a validar diligências policiais em tais circunstâncias, a vedação de invasão de domicílio será reduzida a nada, porque é óbvio que a sua licitude não pode ficar na dependência do êxito ou não da diligência que os policiais arbitrariamente entenderam por bem empreender, como a aqui versada, com invasão da esfera da intimidade de alguém para, só então constatarem a ocorrência de um crime e assim prenderem o suspeito. Não é por cuidar a hipótese de crime permanente que estão legalizados todos os atos praticados pelos agentes públicos. Para se legitimar o flagrante em delitos dessa natureza é necessário que haja fundadas suspeitas sobre o cometimento do crime, e não mera desconfiança" (TJSP; Revisão Criminal 2000948-73.2021.8.26.0000; 1º Grupo de Direito Criminal; j. 09/08/2021).

Desse modo, à luz de tais premissas gerais, ao avançar para a casuística, verifica-se que, diante da tutela constitucional ao direito à privacidade e em especial à inviolabilidade domiciliar, a apreensão da droga na residência de Gabriel, por si só, não está revestida de legalidade.

Portanto, embora as provas apontem sim a materialidade e a autoria da infração penal (notadamente confissão informal e apreensão da droga, conforme indicado pelo Ministério Público), tais provas são ilícitas por derivação e, conseqüentemente, inadmissíveis na forma do art. 5º, LVI, da CR/88 e do art. 157, caput e § 1º do



CPP. Logo, impõe-se a absolvição por ausência de provas lícitas aptas à comprovação da materialidade e autoria da infração penal descrita na denúncia.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de ABSOLVER GABRIEL BRUNO DE OLIVEIRA da imputação contra si formulada neste feito, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Promova-se a destruição das amostras de droga eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Promova-se a restituição dos valores apreendidos ao acusado, na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Sem custas (CPP, art. 804).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica e o acusado.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Valinhos, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA